

1500458-69.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... qual não faz jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei 11.343/06).

Já em relação ao réu YURI, verifica-se que o réu faz jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. De fato, é réu é primário, não possui maus antecedentes como se observa da folha de antecedentes (fls. 52/55) e certidão criminal de (fls. 61).

Não há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500458-69.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500458-69.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL PAULINO DE FARIAS e outro

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

GABRIEL PAULINO DE FARIAS e YURI ROBERTO DE OLIVEIRA BONIFACIO, qualificado nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 4 de janeiro de 2022, por volta das 21h50, na avenida Manoel dos Santos Braga, Vila Robertina, nesta cidade e Comarca de São Paulo, teriam sido flagrados com 226,02 gramas de cocaína e com 110,8, gramas de maconha (tetraidrocanabinol), que, em concurso, teriam trazido consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo alheio.

Segundo conta na denúncia, policiais percorriam a avenida fazendo ronda, cientes de que se tratava de um ponto de venda de drogas, senão quando depararam com os acusados. GABRIEL estaria segurando R\$ 900 e um caderno de anotações; YURI ROBERTO, a seu lado, estaria segurando uma sacola. Os policiais decidiram, então, abordá-los.

Imediatamente, os acusados teriam largado o que tinham nas mãos e se puseram a

correr, mas em vão. Foram alcançados pelos policiais, que lhes deram voz de prisão tão logo constataram que, na sacola que YURI ROBERTO teria deixado para trás, havia 514 porções de cocaína e 55 de maconha acondicionadas em pequenas embalagens de plástico, e que, no caderno de anotações que GABRIEL estaria segurando juntamente com o dinheiro, havia apontamentos cifrados, que se referiam à traficância. Interpelados, os acusados teriam negado que estivessem traficando. YURI ROBERTO teria dito, ainda, que as drogas eram de GABRIEL.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido suas prisões em flagrante convertidas em preventivas (fls. 73/76).

A denúncia foi oferecida às fls. 103/106.

A decisão de fls. 126/127 determinou a citação e notificação dos acusados, reservando desde logo data para realização de audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia 21 de fevereiro de 2022, às 15h.

Os réus foram citados (fls. 146 e 148) e apresentaram defesa prévia por meio da Defensoria Pública (fls. 154).

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 (fls. 155).

Foi concedida liberdade provisória ao réu Yuri, diante de decisão no habeas corpus nº 2000883-44.2022.8.26.0000 (fls. 161).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos das testemunhas, tendo sido os réus interrogados ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, pugnou pela fixação das penas no mínimo legal, com posterior aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, apenas em relação ao réu YURI. Já, a Defesa pugnou pela absolvição dos acusados por falta de provas concludentes, notadamente, acerca da autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pugnou pela concessão de benefícios previstos na Lei Penal aos dois réus.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Ausentes questões preliminares, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudo de constatação (fls. 35/38), laudo pericial definitivo (fls. 156/158), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que os acusados estão envolvidos nos fatos descritos na denúncia.

Vejamos.

Os réus, na fase policial, exerceram o direito constitucional de permanecerem calados (fls. 08 e 09).

Ouvido em Juízo, o réu GABRIEL disse que possui uma companheira e uma filha menor de idade, porém, ainda não registrada em seu nome. Disse ser viciado em "maconha" e bebidas alcoólicas e, trabalhar como vendedor ambulante. Acerca dos fatos a ele imputados, alegou que mora com sua genitora, mas, no dia dos acontecimentos foi até a Vila Robertina para pernoitar na casa de sua companheira e ver sua filha. No caminho, resolveu comprar uma porção de "maconha" e, durante a transação acabou sendo flagrado pelos policiais militares e, preso, de forma equivocada, como traficante. Por fim, disse que já registra uma condenação anterior pelo crime de roubo, bem como, teve passagens policiais na Vara da Infância e Juventude pelos atos infracionais de roubo e tráfico.

A negativa apresentada pelo acusado, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra a saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Ouvido em Juízo, o réu YURI alegou que possui uma companheira, mas não tem filhos. Estudou até o 2º Ano do Ensino Médio, não tem vícios e está desempregado.

Trabalhava como "jovem aprendiz", mas como seu contrato terminou, ficou em sérias

dificuldades financeiras, com o aluguel atrasado, razão pela qual se ofereceu para trabalhar no tráfico. Era o seu primeiro dia de "trabalho" quando foi surpreendido e preso pela Polícia Militar. Por fim, disse que o corréu GABRIEL não estava traficando com ele, apenas tinha passado no local para adquirir um entorpecente e, pediu a ele que segurasse seu caderno de anotações, enquanto ia buscar a droga pedida, porém os policiais chegaram e acabaram prendendo os dois.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A testemunha PABLO LEAL RIBEIRO, policial militar, em fase policial (fls. 06), relatou que, na data dos fatos: estavam em patrulhamento, no local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, já havendo disque denúncia. Chegando ao local, havia dois indivíduos, GABRIEL que estava com o dinheiro na mão, totalizando R\$ 900,00 (novecentos reais), e um caderninho fazendo anotações; enquanto YURI estava com uma sacola preta, que posterior foi encontrada substância análoga a entorpecentes, sendo 514 eppendorfs de cocaína e 55 embalagens de maconha. Ao avistar a viatura, ambos tentaram se evadir, porém, foram capturados logo em seguida. YURI jogou a sacola em cima de um carro, e GABRIEL abandonou o dinheiro e o caderno. Indagados, GABRIEL negou que era dele os entorpecentes, e YURI disse que a sacola e a substância era de GABRIEL, e que era apenas usuário. Utilizado algemas diante a fuga pretérita e receio de nova fuga, e conduzidos ao distrito policial. A testemunha MATHEUS RIOS DE OLIVEIRA, também policial militar, em fase policial (fls. 07), corroborou o relato de seu colega de farda.

Os dois policiais ouvidos durante audiência, confirmaram que no dia dos fatos estavam realizando patrulhamento regular quando se dirigiram até o local indicado na denúncia que, sabidamente, é ponto de tráfico intenso, inclusive, com denúncias via "disque denúncia". Assim que avistaram a viatura policial, os réus tentaram fugir, mas acabaram sendo presos. De imediato, os policiais confirmaram que avistaram YURI com a sacola contendo os entorpecentes apreendidos, enquanto GABRIEL estava fazendo anotações num caderno e contando certa quantia de dinheiro.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão de YURI, bem como, pela quantidade e diversidade da droga apreendida, confirmadas pelo laudo de fls. 156/158, montante consistente em 226 gramas, no qual foi detectada a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), além de um montante consistente em 110,8 gramas, no qual foi detectado a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), bem como pela quantia em dinheiro (fls. 143/144), corroborado pela narrativa dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Destaque-se, por oportuno, que a quantidade e a diversidade da droga apreendida não se presta ao reconhecimento do porte para uso próprio, visto que não se trata, em hipótese alguma, consoante ressaltado, de quantidade irrisória.

A quantidade, a variedade e o modo de disposição das drogas (embaladas individualizadas) e as circunstâncias em que apreendidas, em ponto conhecido como sendo de tráfico de drogas, mostram-se compatíveis com destinação para o comércio

ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido. Apesar da confissão de YURI, inclusive inocentando o corréu GABRIEL, diante dos demais elementos probantes coligidos aos autos, impossível a absolvição de GABRIEL. Ora, os depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo foram uníssonos em informar ao Juízo que avistaram tanto YURI, quanto GABRIEL, os dois juntos trabalhando no tráfico de entorpecentes, sendo certo que, enquanto YURI mexia na sacola com as drogas, GABRIEL contava o dinheiro e fazia anotações num caderno. Frise-se que YURI disse em seu depoimento que entregou seu caderno de anotações para GABRIEL, pedindo que ele o segurasse por alguns instantes. Já, GABRIEL negou, dizendo que nada tinha nas mãos, apenas a quantia de R\$5,00 (cinco reais) que utilizaria para adquirir seu entorpecente. Portanto, ao contrário do depoimento das testemunhas presenciais, os réus não lograram êxito em aprender depoimento único e coeso entre si. Ademais, como já salientamos acima, nada restou comprovado no sentido de que os milicianos que conduziram a ocorrência tivessem interesse específico em prejudicar os acusados GABRIEL e YURI. Desta forma, as palavras do depoimento dos policiais militares devem ser aceitas, como qualquer outra testemunha que, por ventura, tivesse sido arrolada. Isto em conjunto com as demais provas amealhadas em regular instrução em juízo, denotam a incidência da conduta tipificada no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Verifica-se que o réu GABRIEL é reincidente, razão pela qual não faz jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei 11.343/06). Já em relação ao réu YURI, verifica-se que o réu faz jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. De fato, é réu é primário, não possui maus antecedentes como se observa da folha de antecedentes (fls. 52/55) e certidão criminal de (fls. 61). Não há indícios, nos autos, de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Contudo, considerando-se que traficava elevada quantidade de drogas, com diversidade, a fração de diminuição da pena será de 1/3 (um terço). Destaco, por fim que, para não incorrer em bis in idem, as circunstâncias da quantidade e natureza da droga não serão utilizadas na primeira fase da dosimetria em relação a YURI, já que foram consideradas para fixação de patamar menos elevado da causa de diminuição de pena (STF. Plenário. ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014 (repercussão geral)). O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão do réu YURI, corroborada pela narrativa da pormenorizada dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo. Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia. Passo à dosagem das penas que serão impostas aos acusados, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal. RÉU GABRIEL PAULINO DE FARIAS Ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, verifico que culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 (um sexto), visto que praticou crime durante período de cumprimento de pena por outro crime em liberdade condicional (fls. 58), o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda (neste sentido: STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021). Em relação aos antecedentes, verifica-se que, de fato, o réu possui uma condenação transitada em julgado. Todavia, a fim de não cometer bis in idem, ela será utilizada apenas na segunda fase da dosimetria, para configurar o agravante da reincidência.

Embora possua extensa folha de antecedentes infracionais (fls. 56/57), segundo entendimento dos tribunais superiores, os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco para a reincidência ou mesmo valorização negativa de sua personalidade. Culpabilidade, conduta social e personalidade não destoam do ordinário, não devendo ser valoradas.

Quanto às circunstâncias, motivos e consequências do crime também não há nada nos autos que evidenciem a necessidade de maior reprimenda.

Por fim, quanto à circunstância da quantidade e natureza das drogas, verifica-se que expressiva a quantidade de droga encontrada. Os réus traficavam elevada quantidade de drogas, com diversidade. Desta forma, incide aumento de 1/5 (um quinto).

Fica a pena base, portanto, em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é reincidente, como se depreende da certidão de fls. 58/59 (processo 1505013-37.2019.8.26.0228, com trânsito em julgado para a defesa em 29.10.2019).

Fica a pena intermediária em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 797 (setecentos e noventa e sete) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não se verifica qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 797 (setecentos e noventa e sete) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

RÉU YURI ROBERTO DE OLIVEIRA BONIFÁCIO

Ao delito descrito pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, verifica-se que nenhuma das circunstâncias elencadas têm o condão de agravar a pena base do réu, razão pela qual, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça). Desta forma, fica mantida a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, como já assentado na fundamentação, no patamar de 1/3 (um terço). Vão as penas, pois, a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

O regime inicial de cumprimento de pena será ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c" do Código Penal.

Não se aplica o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, já que fixado regime mais favorável.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução número 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável, especialmente considerando-se a natureza e diversidade das drogas apreendidas (art. 44, inciso III, e § 3º, CP).

Tampouco faz jus ao sursis (artigo 77, caput, Código Penal), pela quantidade de pena aplicada.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar os réus:

1) GABRIEL PAULINO DE FARIAS por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06 às penas de penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 797 (setecentos e noventa e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

2) YURI ROBERTO DE OLIVEIRA BONIFACIO, por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06 às penas de penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado GABRIEL no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu GABRIEL na prisão em que se encontra.

Ante o regime imposto, tendo respondido solto, faculto ao réu YURI o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandados de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido ao Funad (depósito a fls. 143), decretado seu perdimento em favor da União; d) não reclamada a restituição do aparelho celular apreendido a fls. 12 em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua destruição; e) oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova f) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA